

1501293-45.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... de fls. 94/96. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial civil Paulo Afonso Cardoso, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que juntamente com outros policiais dirigiram-se ao local dos fatos a fim de inibir o trafico de drogas no local, já conhecido como ponto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501293-45.2021.8.26.0599 - Controle nº 2021/000957

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2225774/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 19721656 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 63/21/594 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9, 2225774 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

JOSMAIR ANTONIO PAULO

Réu Preso

Aos 01 de fevereiro de 2022, às 15:15h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 em razão da pandemia do coronavírus, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: JOSMAIR ANTONIO PAULO - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC PAULO AFONSO CARDOSO - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC FABIO LUIS GONÇALVES HILSDORF - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos das testemunhas PC PAULO AFONSO CARDOSO e FABIO LUIS GONÇALVES HILSDORF.

Após, o réu JOSMAIR ANTONIO PAULO foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MM^a. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: " JOSMAIR ANTÔNIO PAULO, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória de fls. 102/104. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 136), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 139/146), sendo a denúncia recebida (fls. 152/155). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09, fotografia de fls. 10 e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 94/96. A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial civil Paulo Afonso Cardoso, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que juntamente com outros policiais dirigiram-se ao local dos fatos a fim de inibir o trafico de drogas no local, já conhecido como ponto de trafico. Disse que estava em viatura descaracterizada e viu nitidamente o momento em que o acusado, que estava no local, pegou algo dentro de um maço de cigarros, entregou para um transeunte e em seguida escondeu o maço de cigarros. Passou então as informações aos demais policiais e lhe passou suas características físicas e de vestimentas do acusado e também onde havia ele escondido o maço de cigarro. Retirou-se do local a fim de resguardar o sigilo de sua atuação, já que estava em viatura descaracterizada. Seu colega Fabio abordou o réu e realizou as revistas, tendo localizado drogas em poder do acusado e também dentro do maço de cigarro que ele havia escondido. Em poder do acusado foi também localizada certa quantia em dinheiro. No mesmo sentido foram as palavras do policial civil Fabio Luis Gonçalves Hilsdorf., que informou que recebeu informações de seu colega Paulo acerca de eventual pratica de trafico pelo acusado, sendo suas características informadas. Seu colega também lhe informo onde havia ele escondido um maço de cigarro. Assim, realizaram sua abordagem e ,em revista pessoal, localizaram a quantia de dez reais e uma pedra de crack. Localizaram o maço de cigarro que ele havia escondido e dentro do mesmo estavam os demais entorpecentes apreendidos. Indagado, o acusado confessou a pratica do trafico, e disse que após a venda de certa quantidade de drogas recebia uma pedra de crack para seu uso, sendo que aquela droga consigo apreendida era destinada ao seu uso, enquanto as demais porções de cocaína era para venda. Por fim, interrogado, o réu negou os fatos a si atribuídos, alegando que foi até o local dos fatos para comprar uma pedra de crack para seu uso. Disse que foi até a padaria para comprar um maço de cigarros e então foi abordado pelos policiais, que o acusaram de estar traficando. Negou que tenha vendido drogas para um transeunte e negou que tenha escondido o maço de cigarro localizado com as porções de cocaína,. Entretanto, a versão do réu não tem como prevalecer, eis que restou totalmente isolada nos autos. De fato, insta ressaltar que os policiais civis ouvidos foram categóricos ao afirmar que o policial Paulo viu nitidamente o réu entregando drogas e recebendo dinheiro de um transeunte e depois esconder o maço de cigarros onde estavam as porções de cocaína. Confirmaram, também, que indagado, o acusado confessou informalmente a pratica do trafico, tendo informado que vendia drogas e recebia pedras de crack para seu próprio consumo. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. Ainda nesse sentido: PROVA -

TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei). Destarte, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, haja vista que o acusado ostenta maus antecedentes (autos nº 0004959-10.2009 - fls. 106/107; 0008462-10.2007 - fls. 107/108; 0014662-28.2010 - fls. 108/109; 0019976-52.2010 - fls. 109; 0022618-66.2008 - fls. 109/110; 0023032-64.2008 - fls. 110; e 0035790-07.2010 - fls. 111). Na segunda fase, verifica-se que o réu é reincidente (autos nº 0000348-74.2017 - fls. 106). Na terceira fase, ante a reincidência, inaplicável o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Requeiro, por fim, seja decretado o perdimento do valor apreendido com o acusado, consistente em R\$ 10,00 (dez reais), com fulcro nos artigos 61 e 63, ambos da Lei nº 11.343/2006. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao denunciado, razão pela qual deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Paulo, Policial Civil, declarou que estavam apurando crimes de tráfico de drogas em vias públicas. Como a rua das sapucaias é uma rua de incidência constante de tráfico de drogas, dividiram a equipe e a testemunha ficou observando a rua em viatura descaracterizada, sendo que os demais componentes ficariam próximos em viatura caracterizada. Em determinado horário, visualizaram, em uma área verde, um indivíduo transitando pelo local, até que foi abordado por um outro que passou ali, sendo que o réu tirou um maço de cigarros do bolso, tirou um objeto e entregou ao transeunte, recebendo dinheiro em troca. Logo depois, o réu ocultou o maço de cigarros em uma vegetação próxima. Diante disso, solicitou aos componentes da viatura caracterizada que efetuassem a abordagem do réu. Afastou-se depois do local para preservar o caráter sigiloso da operação. Posteriormente, o Fabio lhe comunicou que conseguiram localizar o maço de cigarros, que continha cocaína em seu interior. Não conhecia o acusado antes dos fatos. A testemunha Fabio, Policial Civil, declarou que o Paulo, em viatura descaracterizada, percebeu que uma pessoa estaria no local traficando entorpecentes, passando as características do indivíduo e o local onde ele estaria guardando as drogas. Foi até o local e efetuou a abordagem do réu. Com ele, encontraram a quantia de R\$ 10,00 e uma pedra de crack. Posteriormente, localizaram um maço de cigarros contendo as porções de cocaína. O réu confessou informalmente o tráfico e disse que estava vendendo em troca de pedras de crack para seu consumo pessoal. Não conhecia o acusado antes dos fatos. O réu, em interrogatório, declarou que foi comprar uma porção de crack para seu consumo pessoal. Depois que comprou o crack, foi até a padaria comprar um maço de cigarros. A Polícia chegou e o abordou. Depois de um tempo, eles encontraram o restante das drogas e disseram que elas pertenciam ao réu. Ia usar o cigarro para "fazer cinza" e fumar crack. Recebeu apenas um troco em dinheiro da pedra que comprou. Não escondeu o maço de cigarros em moita nenhuma. Não disse aos Policiais que estava vendendo drogas. Não conhecia os Policiais. O local é conhecido como ponto de tráfico. Portanto, Excelência, o acusado nega a prática dos fatos. Sua negativa deve ser considerada um elemento probatório,

afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais provas dos autos. Isso porque, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Policiais responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem em Juízo a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras de Policiais ou outros agentes de segurança como fundamento para uma condenação: “Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger.” (TJSP – 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin – j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se, pelo próprio depoimento dos Policiais, que, a despeito do suposto “ato de comércio” visualizado antes da abordagem, não foram apresentados outros indivíduos na Delegacia de Polícia como testemunhas presenciais dos fatos e/ou como possíveis usuários das substâncias entorpecentes. Além disso, a mera afirmação de que o local dos fatos seria um “ponto de tráfico” não é presunção absoluta de dedicação do réu ao comércio de entorpecentes, eis que, nesses locais, também circulam usuários dessas substâncias. E a maior parte dos entorpecentes apreendidos pelos Policiais, na realidade, não estava sob a posse direta do réu Jurandir, mas em um local aberto, de livre acesso a qualquer indivíduo. Ou seja, a única circunstância que, em tese, vincularia o acusado ao tráfico de drogas seria uma suposta confissão informal feita no momento de sua prisão, a qual, além de constituir uma circunstância aberrante no ordenamento jurídico, não foi confirmada em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por fim, também é importante mencionar que, recentemente, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, em v. acórdão proferido pela 11ª Câmara de Direito Criminal, que somente a quantidade e variedade de drogas apreendidas com uma pessoa não são elementos suficientes para a caracterização do tráfico, sendo necessários outros fundamentos concretos que atestem o envolvimento do agente no comércio de entorpecentes (Proc. 000843-44.2017.8.26.0559). Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, diante das declarações do acusado em seu interrogatório, a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. Isso porque, com a devida vênia, há de se reconhecer que não há nos autos indícios de que o acusado fosse comercializar as drogas apreendidas, sendo que, reitere-se, não foi verificado qualquer ato efetivo de mercancia dos entorpecentes. Assim, no máximo, o réu poderia ser responsabilizado por portar drogas para fins de consumo pessoal, pois não foi demonstrado cabalmente o intuito lucrativo, não bastando a simples apreensão do entorpecente em poder do acusado para se justificar uma condenação por tráfico. Vale observar, ainda, que a

quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder do réu nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de prova cabal da finalidade de mercancia dos entorpecentes por parte do réu, o que não foi o caso. Todavia, caso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, MESMO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. Isso porque, ainda que considerado reincidente, vale lembrar que a Lei de Drogas, ao fixar como pena mínima, para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para primários, acaba por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que ele integre organização criminosa), é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando a sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela ausência de aplicação da causa de diminuição, uma pena de 5 (cinco) anos. O peso da reincidência, portanto, é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 (um terço) da pena, sendo 2/3 (dois terços) aplicados em função da reincidência. Essa desproporção também é inconstitucional porque atribui, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência implica a aplicação

do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (ou seja, em face de seus antecedentes) e não em função do ato por ele praticado. Como afirma Muñoz Conde: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFE, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo Juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência.” (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Por fim, nem se diga da impropriedade de se afastar uma regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao seu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição (“O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos”, in Direitos Humanos – Visões Contemporâneas, edição de Associação Juizes para a Democracia, 2001). Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sendo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase, a fim de se evitar eventual bis in idem com eventual agravante da reincidência;

(ii) a incidência, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea (ainda que extrajudicial), compensando-a com eventual agravante da reincidência, diante do caráter subjetivo e preponderante de ambas as circunstâncias; (iii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iv) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF – Pleno – HC nº 111.840/ES – rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ e, ainda, em razão do disposto no art. 387, § 2º, do CPP; (v) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento processual, a manutenção de sua prisão preventiva".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

JOSMAIR ANTONIO PAULO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput" da Lei 11.343/06

Consta da denúncia que, no dia 19 de agosto de 2021, por volta das 11h, na Rua das Sapucaias, bairro Mario Dedini, nesta cidade e comarca de Piracicaba, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, o réu trazia consigo, para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 01 (uma) porção de cocaína, na forma de "crack", com massa líquida de 0,2g (dois decigramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica. Consta, ainda, que, no mesmo dia, logo em seguida, em aérea verde, localizada na Rua das Sapucaias, bairro Mario Dedini, nesta cidade e comarca de Piracicaba, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, o réu tinha em depósito, para fins de venda ou entrega, de qualquer forma, a consumo de terceiros, 10 (dez) frascos plásticos, tipo "eppendorf", contendo cocaína, com massa líquida de 1,8g (um grama e oito decigramas), substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica.

Narra a denúncia que, na data dos fatos, policiais civis em uma viatura descaracterizada, encontravam-se em diligências no local dos fatos, que é conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes, quando avistaram o acusado praticando atos característicos de comercialização de droga, eis que retirou algo de um maço de cigarros que estava no bolso de sua calça e entregou a um transeunte. Em seguida, recebeu uma cédula de dinheiro. Após, o acusado ocultou o maço de cigarros em uma moita, em uma área verde. Diante disso, os policiais abordaram o acusado, obtendo êxito em localizar com ele uma porção de "crack", além da quantia de dez reais em dinheiro. Realizada busca no local onde o acusado havia ocultado o maço de cigarros, foi este encontrado, o qual continha dez porções de cocaína. Inquirido pelos policiais, JOSMAIR ANTÔNIO admitiu, informalmente, que estava comercializando droga no local e que a cada cinco porções de cocaína, que vendia a dez reais, recebia uma pedra de "crack". As substâncias foram devidamente apreendidas e submetidas a exames de constatação provisória e químico-toxicológico, os quais resultaram positivo para "crack" e cocaína.

O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 136) e apresentou defesa preliminar (fls. 139/146), seguindo-se a decisão de fls. 152/155, que recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Designada audiência, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu.

As partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 94/96, que trouxe

resultado positivo para cocaína.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu fez uso do direito de permanecer em silêncio (fls. 04).

Em juízo, negou a prática do crime. Disse que, no dia dos fatos, foi buscar pedra de crack para fumar. Após, foi ao bar pegar um maço de cigarros. Então, foi abordado pelos policiais, que encontraram a pedra de crack em seu poder e o cachimbo. Alegou que, na sequência, eles o algemaram e o colocaram na viatura.

Disse que não entregou droga para ninguém e só recebeu de uma pessoa o troco da compra que fez. Aduziu que tampouco dispensou um maço de cigarros contendo drogas.

A prova produzida nos autos, porém, é maciça e incriminadora.

Com efeito, o policial civil Paulo Afonso relatou que se dirigiram ao local dos fatos, posto que é conhecido ponto de tráfico, tendo permanecido fazendo observação em viatura descaracterizada, enquanto os demais membros da equipe estavam numa viatura caracterizada, em outro local. Disse que avistou o réu, que permanecia no local, até ser abordado por um transeunte. Então, o réu retirou algo de um maço de cigarro, entregou ao transeunte, que lhe deu uma cédula de dinheiro. Após, o réu ocultou o maço de cigarro numa vegetação próxima. Diante disso, solicitou aos componentes da viatura que fizessem a abordagem, passando suas características e o local onde ele ocultou o maço de cigarros. Posteriormente, foi informado pelo policial Fabio que, feita a abordagem, a equipe encontrou o maço de cigarros contendo dez porções de cocaína e uma cédula de dinheiro com o réu.

O policial Fabio Luís, por sua vez, asseverou que o policial Paulo fazia campana em viatura descaracterizada e identificou uma pessoa praticando o tráfico, informando suas características e o local onde guardava a droga. Afirmou que estava numa viatura caracterizada e foi ao local. Disse que fizeram a abordagem do réu e, em poder dele, encontraram uma pedra de crack e R\$ 10,00 e no local. Já no local informado pelo parceiro, encontraram um maço de cigarros com dez eppendorfs de cocaína. Aduziu que o réu confessou a prática do crime e disse que vendida cada porção de cocaína a dez reais e, conforme fazia as vendas, receberia uma pedra de crack.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais civis não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais civis é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes.

Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665).

Enfim, o fato de os policiais, durante campana com viatura descaracterizada, terem visualizado o acusado no local dos fatos, em atividades típicas de traficância, entregando algo para um transeunte e recebendo uma cédula de dinheiro em troca, e, logo após, terem apreendido uma porção de "crack" e R\$10,00 em dinheiro em poder dele, bem como que 10 porções de cocaína escondidas em uma moita na área verde próxima ao local da abordagem, que ele acessara anteriormente, conduz à certeza quanto à autoria e a destinação das porções de cocaína apreendidas ao comércio ilícito.

Observo que a quantidade de entorpecentes apreendida e a forma como estavam acondicionados, aliados ao local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico, e as circunstâncias da apreensão, evidenciam mesmo que as porções de cocaína se destinavam ao comércio ilícito.

Importa anotar que os entorpecentes apreendidos estão em consonância com o quanto foi flagrado pelo policial Paulo e também com o declarado pelo réu informalmente, no momento da abordagem, sendo verossímil a assertiva de que recebia uma pedra de crack para seu uso conforme efetuava a venda das porções de cocaína. Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Consigno, outrossim, que o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498).

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que o réu ostenta Maus Antecedentes (autos nº 0008462-10.2007 da 3ª Vara Criminal local, 0014662-28.2010 da 1ª Vara Criminal local, 0022618-66.2008 da 2ª Vara Criminal local, 0023032-64.2008 da 3ª Vara Criminal local e 0035790-07.2010 da 3ª Vara Criminal local - certidão a fls. 106/112).

De acordo com o art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência, mas podem ser consideradas como Maus Antecedentes, nos termos do art. 59 do mesmo código.

Nesse sentido decisão do C. STJ: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES.

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que à luz do art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência mas podem ser consideradas como Maus Antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal. 2. Considerando que o ordenamento jurídico pátrio adota quanto aos Maus Antecedentes o sistema da perpetuidade, e não da temporariedade, como no caso da reincidência, é de se manter o entendimento pacificado por este Sodalício de que, mesmo ultrapassado o prazo depurador, as condenações anteriores podem ser consideradas como Maus Antecedentes. 3. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp nº 1.604.407/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 12.08.2016).

E o STF, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos Maus Antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, em seu valor mínimo legal.

Na segunda fase da fixação da pena, observo que o acusado é triplamente reincidente (autos 0000348-74.2017 desta 4ª Vara Criminal, 0004959-10.2009 da 2ª Vara Criminal local e 0019976-52.2010 da 3ª Vara Criminal local - fls. 106/112 e informações da F.A da VEC a fls. 113/129), razão pela qual aumento a pena de um quinto, resultando sete anos, dois meses e doze dias de reclusão e setecentos e vinte dias-multa - multa, no valor unitário mínimo legal.

Não há circunstâncias atenuantes.

Inexistem causas de aumento e, por ser o réu reincidente e portador de Maus Antecedentes, não faz jus à redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, por ser o réu reincidente e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a

hediondo.

A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º, inciso XLIII).

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, a qual não pode ser tornada insubsistente, sobretudo em razão da superveniência de sentença condenatória pela prática de crime equiparado a hediondo.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

Porque demonstrada a origem ilícita do dinheiro apreendido, declaro o seu perdimento.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar JOSMAIR ANTONIO PAULO, qualificado nos autos, à pena de sete anos, dois meses e doze dias de reclusão e setecentos e vinte dias -multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, fixado o regime inicial fechado e vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias. Declaro perdido o dinheiro apreendido.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela MMª. Juíza de Direito, a seguir, foi dito:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 31/01/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o

presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MM^a. Juíza de Direito da 4^a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo
JUÍZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]